

在第二笔犯罪事实中，董某某明知自己没有能力帮助何某某“捞人”，仍声称其可以疏通关系帮助被害人的丈夫办理保外就医，虚构了事实上和法律上不可能的事实，很显然是“无中生有型”欺诈。综上，董某某主观上非法占有他人财物的故意明显，客观上实施了借“捞人”之名虚构事实，骗取他人财物且数额巨大，构成诈骗罪。

二、刑事诉讼中基于不法原因给付的财物的处置

刑事诉讼中，对于违法所得的处置，《中华人民共和国刑法》第六十四条规定，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。也就是说，被害人的合法财产，应当返还被害人。本案中，何某某支付给董某某的9万余元“打点费”原本是其自身的合法财产，但是其基于不合法的目的，在董某某的诱导下进行了处置，该财物的性质自然发生了变化。此时，该财物应当如何处置，确实值得商榷。

实践中，对于不法原因给付的财物是否应当返还给付人存在争议，各地的判决不一，有判决返还给付人的，也有判决予以没收的。笔者赞同判决予以没收的意见，理由有：一方面，与《中华人民共和国刑法》第六十四条保护被害人合法财产的规定相一致。被害人基于不法原因给付财物，委托的往往是违法行为，其给付的财物也随之发生质的变化。另一方面，与我国民法典保护当事人合法权益的理念相一致。《中华人民共和国民法典》第三条规定，民事主体的人身权利、财产权利以及其他合法权益受法律保护，任何组织或者个人不得侵犯。即保护的也是合法权益。再者，《中华人民共和国刑法修正案(十二)》对《中华人民共和国刑法》第三百九十条作了大篇幅修改，尤其是新增了对司法人员的行贿属于从重处罚情形。本案中，何某某为了谋取不正当利益，企图通过董某某给予司法人员财物，本意就是行贿，这种行为违反了我国有关法律和政策的强制性规定，违背了公序良俗，也助长了社会上的不正之风，其行为目的和手段都不合法。因此，对何某某给付董某某的财物即董某某的违法所得，

判决追缴后予以没收，上缴国库，符合我国法律的规定及司法理念的要求。综上所述，对董某某的违法所得94800元，应当在追缴后予以没收，上缴国库。

编写人：广西壮族自治区昭平县人民法院 卢春燕

明知他人实施电信网络诈骗犯罪， 利用“GOIP”网关设备远程提供支持，构成诈骗罪

——谭某、陈某诈骗案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广西壮族自治区来宾市兴宾区人民法院(2023)桂1302刑初18号刑事判决书